

1500829-86.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Registre-se que a circunstância de o acusado ser usuário de drogas e de exercer trabalho lícito não afastam por completo a possibilidade de, paralela e concomitantemente, concorrer para o tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista - SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500829-86.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500829-86.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DOBARRO GARCIA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de BRUNO DOBARRO GARCIA DA SILVA, na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do art. 33 da Lei 11.343/2006. .

Narra-se na denúncia que " no dia 27 de julho de 2021, por volta de 16h00min, na Travessa Porto Rico, 174, Laranja Azeda, cidade de Bom Jesus dos Perdões, nesta comarca de Nazaré Paulista, trazia consigo, para fins de tráfico, 39 porções de crack, com peso líquido de 8,1g, 73 porções de cocaína, com peso líquido de 75,5g, e 7 porções de Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 12,6g, sem autorização legal ou regulamentar. Segundo o apurado, o denunciado resolveu praticar o tráfico ilícito de drogas e, assim, obteve quantidade de cocaína, crack e maconha, as quais foram acondicionadas em porções individuais, para a pronta entrega ao consumo de terceiros. Assim, no local apontado, o denunciado trazia consigo as porções individuais das drogas e aguardava o contato de possíveis compradores e usuários."

A denúncia foi recebida em 09/11/2021.

Citado 179, o denunciado apresentou resposta à acusação (fls. 142 a 148).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação de atenuantes e causas de diminuição de pena.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. .

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3), pelo laudo de exame pericial (fls. 128/120), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

Assim, Alisson Francisco de Oliveira, testemunha, em resumo, depôs que em patrulhamento pelo local, avistaram um indivíduo pela via. Ao abordá-lo, o indivíduo evadiu-se por um terreno baldio, dando fundos para uma residência. Subiu na laje e pulou no terreno desta residência, que saía na Trav. Nicarágua. Ao pular o muro, o investigado fraturou o tornozelo esquerdo. Abordado, em busca pessoal foi localizada uma embalagem plástica, na qual foram localizadas 73 porções de cocaína, 39 pedras de crack, sete porções de maconha e R\$ 50,00. Indagado, informou que estava no tráfico pela Trav. Porto Rico e se evadiu por ter medo de ser preso. Foi então exarada a voz de prisão em flagrante delito e devidamente socorrido.

De outro lado, Serafim Matheus de Oliveira, testemunha, em resumo, afirmou que estavam em patrulhamento quando ao ultrapassar uma travessa o acusado empreendeu fuga, a pé, e entrou em um terreno baldio, pulou na laje de uma residência e então ingressou no terreno, mas quebrou o tornozelo na queda; que então deu a volta com a viatura e o abordou no interior da residência; que encontrou com ele 73 porções de cocaína, 39 de crack e 7 maconha, mais cinquenta reais em dinheiro; que ele confessou que estava traficando e correu por medo de ser pego; que a moradora da residência, Gloria, presenciou toda a ação; que nunca tinha o abordado anteriormente, mas o conhecia de vista; que a travessa em que o acusado foi abordado é conhecida como ponto de tráfico de drogas; que seu parceiro à época era Alisson; que estava em dupla com ele e não têm parentesco entre si; que não sabe se Alisson já abordou o acusado anteriormente; que tanto ele quanto Alisson respondem por uma denúncia por agressão; que estão em patrulhamento normal.

Já Alisson Francisco de Oliveira relatou que estavam em serviço em patrulhamento no Parque Hortênsia e quando estavam na Travessa Porto Rico visualizaram um indivíduo e foram abordá-lo, mas ele seguiu correndo; que tentaram segui-lo, mas ele entrou numa residência que sai para outra rua; que, quando foi no encalço, o acusado pulou uma laje e caiu no chão, e se machucou, mas tentou ainda assim se levantar, mas seu parceiro deu a volta e conseguiu abordá-lo; que ele declarou que estava traficando e fugiu porque estava com medo de ser preso; que ele foi conduzido para atendimento médico em razão da lesão no pé; que não conhecia o acusado; que a travessa é conhecido ponto de tráfico de drogas; que a busca pessoal ocorreu na rua debaixo; que quem achou a droga com ele foi Matheus; que só estava com Matheus, não havia outra viatura; que respondeu por sete processos disciplinares e em todos eles foi absolvido.

Por fim, o acusado Bruno Dobarro Garcia da Silva relatou que é usuário de drogas, tem problema compulsivo com drogas e o bairro onde mora há vários pontos de tráfico; que no dia recebeu uma proposta para fazer tráfico e então, para usar, acabou pegando a droga; que de fato a viatura apareceu, acabou fraturando a tibia ao pular da laje; que estava com maconha e cocaína; que a droga era para vender e para usar também; que nesse dia tinha usado droga; que lembra da viatura ter

chegado e assim que apareceu correu, no sentido do terreno baldio, pulou a laje, os policiais fizeram a revista, não objetou, só disse que perdeu e realmente estava traficando, e depois foi ao hospital e tomou alguns remédios; que nunca chegou a ser internado por dependência química; que mora com sua mãe; que é usuário de cocaína e maconha e o quanto usa por dia varia, às vezes cinco porções de cocaína e duas de maconha; que tinha trabalhado no dia anterior apenas; que trabalha de segunda à sexta, das três às sete da manhã; que na acusação anterior foi pego com maconha.

Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem do acusado e quanto à apreensão da droga em sua posse. De outro lado, observa-se que o próprio acusado reconheceu que foi surpreendido em posse da droga, reconhecendo a dinâmica da abordagem e da perseguição policial e esclarecendo que se lesionou ao pular da laje, afastando assim a tese de eventual abuso ou violência policial. Confessou, então, espontaneamente, a posse da droga e a destinação ao tráfico. Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas. Registre-se que a circunstância de o acusado ser usuário de drogas e de exercer trabalho lícito não afastam por completo a possibilidade de, paralela e concomitantemente, concorrer para o tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas

no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que o acusado praticou conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a fim de evitar punição dúplice pelo mesmo fato (*bis in idem*), tal registro negativo será considerado apenas como reincidência na segunda fase, sem produzir efeito nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), verifica-se que houve a apreensão de três espécies de droga, mas todas em reduzida quantidade, de modo que não há fundamento suficiente para a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea e incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), as quais podem ser compensadas entre si na forma do art. 67 do CP.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva deve ser mantida no patamar da pena provisória.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu em razão da reincidência. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe

04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado BRUNO DOBARRO GARCIA DA SILVA ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, e 65, III, “d”, do CP.

Quanto à manutenção prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único). Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Nazaré Paulista, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA